

1500683-65.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... no local dos fatos estava ocorrendo o tráfico de drogas, por um indivíduo de cor parda, que vestia camiseta e bermuda. Afirmou que três pessoas foram até os policiais e fizeram as denúncias, sendo que em datas anteriores já tinham recebido denúncias de que ocorria o tráfico no local. Foram até o condomínio, desembarcaram próximo e nos fundos visualizaram o indivíduo com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500683-65.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500683-65.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN HENRIQUE DE OLIVEIRA AMARO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

BRYAN HENRIQUE DE OLIVEIRA AMARO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na denúncia, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 11h30min., na área comum do condomínio da CDHU, situado na Rua Aviação, nº 1.520, bairro Santana, nesta cidade e comarca de Araçatuba-SP, o réu tinha em depósito e trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 12,84 gramas de Benzoilmetilecgonina, em pó e em pedras de "crack", substância entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", droga capaz de causar dependência.

O réu foi preso em flagrante em 06/05/2021 (fl. 08). Pela r. decisão de fls. 62/67 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido em 07/05/2021 (fls. 83/84).

Devidamente notificado (fl. 120), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 125/129. Pela r. decisão de fls. 135/137 foi deferida a gratuidade de justiça em favor do acusado e recebida a denúncia em 05 de outubro de 2021. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 168/172).

Em alegações finais (fls. 177/183), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa, requerendo o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da União, por se tratar de produto do crime, bem como seja observada na dosimetria da pena que o acusado já foi condenado por crime da mesma espécie.

Em alegações finais (fls. 187/215), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado diante da fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de dois terços; a imposição de regime inicial aberto para cumprimento da pena, em observância ao artigo 387, § 2º, do CPP e Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça; a substituição da eventual pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudos de constatação prévia de substâncias entorpecentes (fls. 22/27), laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 90/95), relatório policial (fls. 96/97), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A testemunha comum Wagner Antonio da Silva, policial militar ouvido em juízo (fl. 09), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram informados por três pessoas, em horários diferentes, que estava ocorrendo a venda de entorpecentes na área comum do condomínio da CDHU, numeral 1.520. Relatou que havia várias denúncias, via COPOM, da venda de entorpecentes no local dos fatos. Disse que foram até o local, desembarcaram da viatura um quarteirão antes e se dirigiram até os fundos do condomínio, ocasião em que visualizaram o indivíduo na área comum do condomínio, cujas características eram idênticas com aquelas informadas nas denúncias. Observaram o momento que o réu fez contato com um suposto usuário, ocasião em que recebeu algo e depois entregou algo para o usuário, o qual foi embora da área comum. Diante das evidências do crime, retornaram para a viatura e foram até a frente do condomínio. Ao chegarem no local, o acusado visualizou a presença dos policiais e correu para os fundos do condomínio, sendo que pulou vários muros e saiu numa rua lateral, descendo uma rua de ladeira sentido à Avenida João Arruda Brasil. O acusado foi perseguido pelo Soldado Wilyan. Disse que o réu caiu na rua de ladeira, se levantou e continuou fugindo, se escondendo dentro de um "valetão", entre uns galhos de árvore, sendo abordado pelo Soldado Wilyan. Relatou que chegou

em seguida ao local e fez a busca pessoal no acusado, ocasião em que localizou a quantia de R\$ 100,00 no bolso do réu e 03 (três) pinos de cocaína. Ao ser indagado, o acusado confessou a venda da droga e indicou onde estavam os demais entorpecentes na área comum do condomínio, que foram encontrados dentro de uma fissura de concreto no chão, debaixo de uma grama. Disse que foram encontrados mais 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, idênticos àqueles que o acusado portava, além de 08 (oito) pedras de "crack". Relatou que no dia dos fatos, receberam três denúncias de pessoas diferentes, em questão de minutos, os quais encostavam na viatura policial e informavam a venda das drogas no local dos fatos. Disse que as características informadas eram de um indivíduo pardo, estatura mediana, que vestia short colorido e blusa vermelha, sendo que tais características coincidiram com o acusado. Afirmou que se o réu não tivesse indicado o local onde estavam os demais entorpecentes, seria muito difícil localizá-los, a não ser que tivessem ajuda do canil da Polícia Militar. Declarou que a distância entre o local que o réu foi avistado comercializando a droga, na área comum, e o local da abordagem era mais de cem metros. As drogas estavam escondidas próximas a uma lixeira. Não conhecia o acusado e não tinha sido informado anteriormente por nenhum usuário que o réu estava traficando drogas, porém, após pesquisa no COPOM, verificaram que o acusado registrava antecedente criminal por tráfico de drogas. Relatou que, no local dos fatos, os moradores não querem conversar com a polícia porque têm medo de represálias, mas em local distante é comum que façam denúncias aos policiais. Informou que não fizeram tocaia, apenas desembarcaram da viatura, foram até os fundos do condomínio e ficaram no local por volta de cinco minutos, ocasião em que visualizaram o acusado, com as mesmas características das denúncias, fazendo contato com um suposto usuário, em ato típico de mercancia. O suposto usuário estava de bicicleta e fez contato com o réu, entregando-lhe algo e recebendo algo de volta do acusado. Do local em que o réu estava vendendo droga até o local onde foram encontrados o restante dos entorpecentes, havia dez metros de distância. O acusado alegou que estava vendendo drogas porque sua companheira estava grávida e precisava levantar um dinheiro.

A testemunha comum Wilyan Menezes de Araujo, policial militar ouvido em juízo (fl. 171), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 11), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando algumas pessoas informaram que no local dos fatos estava ocorrendo o tráfico de drogas, por um indivíduo de cor parda, que vestia camiseta e bermuda. Afirmou que três pessoas foram até os policiais e fizeram as denúncias, sendo que em datas anteriores já tinham recebido denúncias de que ocorria o tráfico no local. Foram até o condomínio, desembarcaram próximo e nos fundos visualizaram o indivíduo com as mesmas características, na área comum do condomínio, fazendo contato com uma pessoa de bicicleta. Visualizaram que o acusado estava realizando o tráfico no local. Relatou que deram a volta para entrar pela frente do condomínio. Quando chegaram na frente, o réu visualizou a equipe policial e correu para os fundos. O indivíduo de bicicleta se evadiu e não foi possível abordá-lo, uma vez que foram atrás do acusado que estava realizando a venda da droga. Disse que foram ao encalço do réu, o qual pulou o muro e acessou a rua lateral. Em dado momento, o acusado caiu, rolou pelo chão, se levantou e continuou correndo, sendo que entrou numa área onde há um córrego, tentando se esconder. O depoente avistou o acusado e conseguiu abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram na posse do réu a quantia de R\$ 100,00 e 03 (três) microtubos da cor amarela, contendo cocaína. Ao ser indagado, o acusado confessou que realizava o tráfico no condomínio e trazia consigo aquelas drogas e o dinheiro que era proveniente da venda, bem como deixava o restante dos entorpecentes no condomínio. Disse que retornaram ao condomínio e o réu indicou o local onde estava o restante das drogas, ocasião em que encontraram mais 37 (trinta e sete) microtubos da mesma cor e 08 (oito) pedras de "crack" enroladas num plástico. Não conhecia o acusado e não tinha sido informado anteriormente que o réu estava traficando drogas no local. Afirmou que as cores das vestes não foram citadas nas denúncias, somente a cor da pele do indivíduo, que era parda escura, bem como que trajava camiseta e bermuda. O local onde estava o restante da droga era de difícil acesso, pois estavam

escondidas. Disse que o acusado foi avistado dentro do condomínio, na área comum, a uma distância de cinco a dez metros do local onde estavam as drogas. Relatou que o réu foi abordado cerca de quinhentos metros a um quilometro (dois quarteirões) de distância do condomínio. O acusado informou que tinha uma mulher grávida e estava traficando porque precisava de dinheiro. Não teve conhecimento naquela ocasião que o réu estava envolvido com outro crime de tráfico.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 168/169), o réu Bryan Henrique de Oliveira Amaro negou a prática do delito. Disse que foi ao condomínio porque era usuário contumaz de maconha e iria buscar a droga. Quando iria pegar a droga, os policiais invadiram o local e o dono do entorpecente saiu correndo. Disse que ficou no local e foi abordado pelos policiais, sendo encontrado em sua posse somente a quantia de R\$ 100,00 em dinheiro. Os policiais perguntaram quem tinha corrido, sendo que disse a eles não saber quem era e que tinha apenas ido ao local comprar maconha para consumi-la. Negou que estivesse na posse de cocaína ou maconha. Negou que tenha corrido dos policiais. Afirmou que foi o moleque que estava vendendo a droga quem fugiu. Os policiais disseram que o interrogando seria preso se não relatasse quem era o dono das drogas que eles encontraram na lixeira. Afirmou que viu os policiais vasculhando o local, ocasião em que disseram que o interrogando seria preso. Não sabe o motivo da sua prisão. Na época, trabalhava como mecânico com seu primo, sendo que foi ao local apenas comprar um baseado de maconha, no horário do seu almoço, sendo que voltaria em seguida para o seu trabalho. Afirmou que trabalhava na Rua Luiz Mitidiero, numeral 521, numa oficina de motos chamada "13 Motos". Relatou que seu patrão chamava Leandro e trabalhava no local com o indivíduo de nome Gabriel Faria. Disse que ganhava R\$ 1.200,00 por mês. A esposa do interrogando estava grávida na época, sendo que seu filho já nasceu. Relatou que morava no Jardim Universo, que fica a seis quarteirões de distância do local dos fatos. Não conhecia os policiais. Disse aos policiais militares que sua esposa estava grávida. Informou que já tinha sido preso em 2019, por tráfico de drogas, na rua de sua casa, porém, foi preso por outros policiais militares. Naquela ocasião, o interrogando estava com 50 gramas de "crack" que iria vender. Nunca foi preso na adolescência com drogas. Afirmou que os policiais o prenderam por causa do seu antecedente criminal. Reiterou que não estava com drogas e não vendia entorpecentes. O dinheiro apreendido seria usado para comprar uma "balinha" de maconha. Afirmou que não havia drogas próximas ao interrogando. Por fim, disse que os policiais não foram até sua residência.

Eis a prova oral colhida.

Encerrada a instrução processual, restou comprovado que os entorpecentes apreendidos nos autos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas comuns em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.

Os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem em solo judicial que durante patrulhamento receberam denúncias de três pessoas informando que um indivíduo de cor parda, estatura mediana, que vestia camiseta vermelha e bermuda/short colorido – conforme relatou a testemunha Wagner Antonio da Silva –, estaria traficando entorpecentes na área comum do condomínio da CDHU. No local, os agentes públicos avistaram o acusado, com as mesmas características físicas e vestes informadas na denúncia, em ato típico de mercancia da droga, uma vez que fez contato com um indivíduo de bicicleta que lhe entregou algo e depois recebeu algo de volta, se evadindo do local.

Em razão da atitude suspeita do acusado, aliado às denúncias recebidas naquela ocasião, bem como ao fato de que o local era conhecido pelas testemunhas por outras denúncias de tráfico de drogas, os agentes públicos decidiram efetuar a abordagem do réu, que se evadiu do local quando avistou os policiais militares.

Após a perseguição policial, o acusado foi detido e revistado, ocasião em que os policiais encontraram em sua posse 03 (três) microtubos plásticos contendo cocaína e mais R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. De acordo com as testemunhas, o réu assumiu a propriedade da droga e do dinheiro apreendido – o qual era proveniente da venda de entorpecentes –, bem como confessou que estava comercializando drogas na área comum do condomínio, tendo indicado o local exato onde estava escondendo o restante dos entorpecentes. As testemunhas retornaram ao condomínio e no local indicado pelo acusado foram encontrados mais 37 (trinta e sete) microtubos plásticos de cocaína, idênticos àqueles que o réu trazia consigo, além de 08 (oito) pedras de “crack”

Não há motivos para desmerecer a palavra dos policiais militares, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição/apreensão de fls. 18/19 e laudos periciais de fls. 22/27 e 90/95.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 09 e 11), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

De resto, tenho que pequenas divergências em questões secundárias – como o fato de a testemunha Wilyan Menezes de Araujo ter afirmado que nas denúncias não foram informadas as cores das vestes do acusado, ao contrário do que declarou Wagner Antonio da Silva – não se presta a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências dessa natureza atendidas pelos policiais militares.

Neste passo, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, visto que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestarem testemunho sob o compromisso da lei.

No caso vertente, não há qualquer indício nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido em juízo e “forjado” o flagrante das drogas para tentar prejudicar o acusado. Não há motivos para acreditar que abordaram o réu com a única finalidade de incriminá-lo e prendê-lo em flagrante por não ter colaborado com a identificação do suposto verdadeiro traficante que estaria no local vendendo droga para o acusado, aliado ao fato de que o réu já tinha sido preso em ocasião anterior, também por tráfico de drogas, como alegou em seu interrogatório na fase judicial.

Ressalta-se que os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem em solo judicial que não conheciam o acusado e não tinham qualquer informação prévia acerca da prática do delito pelo réu, sendo que ele próprio, também em juízo, declarou que não conhecia os agentes públicos, tendo afirmado que sua prisão anterior foi realizada por outros policiais militares.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva de que a inicial acusatória se baseia apenas nos depoimentos contraditórios apresentados pelos agentes públicos.

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, em que pese ter negado a prática do delito, tanto na seara policial (fl. 13) quanto judicial – afirmando que não trazia consigo nenhum entorpecente, tampouco que escondia drogas na área comum do condomínio e não estava realizando a comercialização ilícita no local, sendo que apenas foi ao condomínio adquirir uma porção de maconha de um traficante que se evadiu após a chegada dos policiais militares –, observa-se que sua versão exculpatória não é crível, conforme anteriormente exposto, sendo infirmada pela prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se que em solo policial (fl. 13), o acusado relatou ter corrido dos agentes públicos e tentado pular o muro do condomínio para se evadir, ocasião em que foi alcançado e agredido fisicamente pelos policiais. Contudo, o réu alterou sua versão em solo judicial, afirmando que em nenhum momento correu para evitar a abordagem, tampouco mencionou as supostas agressões perpetradas pelos policiais militares.

Por outro lado, como bem destacou o ilustre representante do Ministério Público em alegações finais, “A prova de que as drogas citadas na denúncia estavam na posse do acusado e eram destinadas à traficância é irrepreensível, improfligável. De destacar-se, segundo declararam os policiais ouvidos neste feito, que eles não teriam encontrado as 08 porções de crack e os 37 pinos de cocaína citados na denúncia se o acusado não lhes tivesse indicado o local onde os mantinha escondidos.” (fl. 178), considerando que ambas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que os entorpecentes estavam bem escondidos, em local de difícil acesso.

Imperioso ressaltar que as versões apresentadas pelo réu não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova colhido nos autos, tratando-se de versões frágeis e destituídas de qualquer suporte probatório que lhe deem sustentação, razão pela qual não merecem credibilidade.

O modo como as drogas estavam acondicionadas e a quantidade apreendida demonstram, de fato, que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. Isto porque, foram apreendidas 12,84 gramas da substância entorpecente “benzoilmetilecgonina”, popularmente conhecida como “cocaína”, distribuídas em 40 (quarenta) microtubos plásticos do tipo “eppendorf” e 08 (oito) porções de material sólido petrificado, na forma de “crack”, conforme laudos periciais de fls. 22/27 e 90/95.

Registre-se, ainda, que no mesmo contexto fático foram apreendidos R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, na posse do acusado, o que corrobora com a versão de que estava traficando drogas no local dos fatos, uma vez que é comum os agentes carregarem consigo os valores oriundos das vendas que realizam.

Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja o agente flagrado em atos de mercancia ou na posse de apetrechos comumente utilizados para a prática do delito.

Portanto, as provas são robustas a sustentar um decreto condenatório, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

No tocante à quantia de R\$ 100,00 (cem reais) apreendida nos autos (fls. 18 e 89), observa-se que o acusado não comprovou a origem lícita do dinheiro, tendo o numerário sido apreendido nas mesmas circunstâncias fáticas dos entorpecentes – uma vez que estava dentro do bolso em que foram encontradas as drogas com o acusado, considerando, ainda, que o réu confessou informalmente aos agentes públicos que o

dinheiro era proveniente da mercancia ilícita -, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga.

Com efeito, as condutas do réu, consistentes nas ações de "trazer consigo" e "ter em depósito" os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no "caput" do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Analisando os autos, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em favor do acusado.

Conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, a inserção no ordenamento jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o agente preenche cumulativamente todos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena (REsp nº 1.380.741/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado está sendo processado por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em data anterior (18/08/2019), inclusive com condenação em 1ª Instância, encontrando-se os autos em grau de recurso (processo nº 1501303-48.2019.8.26.0603 - fl. 42).

Sendo assim, diante da ação penal em curso, também por tráfico de drogas, bem como as demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido se posicionou o C. STJ:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. (...) Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça." (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017, g.n.).

Em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 42/43), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada.

Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Inviável, no caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), excepcionalmente, pois o correto seria a fixação do regime fechado, considerando no presente caso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, o montante da pena imposta, a quantidade da droga apreendida (12,84 gramas de "cocaína"), bem como em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), por conta de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, inciso I e 77, "caput", ambos do Código Penal, bem como por não se considerar aptas para retribuição e prevenção da pena a mencionada substituição e fixação de regime prisional menos gravoso no presente caso, além de causar verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Araçatuba-SP.

Por fim, incabível em sede de sentença condenatória a aplicação da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, devendo o Juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração e progressão do sentenciado para regime mais benéfico, porquanto não se têm nos autos informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação carcerária do condenado, impedindo a análise do requisito subjetivo. E, com a prolação da presente sentença, a detração já poderá ser requerida perante o Juízo da execução, mesmo se tratando de guia de recolhimento provisória, conforme será determinada a expedição.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu BRYAN HENRIQUE DE OLIVEIRA AMARO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime semiaberto para o início do cumprimento.

Não defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos explicitados para decretação e manutenção de sua prisão preventiva, somado à gravidade do crime imputado, bem como para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo agora diante da condenação, em razão do montante e regime de pena impostos.



Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional onde se encontra. Após, com a intimação das partes acerca da presente sentença, expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória/definitiva.

DECLARO o perdimento da quantia apreendida nos autos (R\$ 100,00 - fl. 89) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que é produto do crime praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade de justiça concedida em favor do réu (fl. 136).

P. R. e I.

Araçatuba, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA